

1505949-77.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como as porções apreendidas estavam embaladas, características típicas do tráfico em larga escala.

Anote-se, além disso, que o próprio acusado confessou que recebeu R\$ 13,00 para fazer o transporte da droga e que as porções seriam entregues a 400 metros de distância do local onde se deu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505949-77.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505949-77.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON PEREIRA PINTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Emerson Pereira Pinto foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Benedito Maia de Figueiredo, em frente ao numeral 660, Vila São Pedro, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações da entidade beneficente ADEFIVI, do estabelecimento de ensino CEI "Padre Longino Vastbinder" e da Unidade de Saúde da Família do Jardim Santa Terezinha, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 90 microtubos contendo cocaína, pesando 60,17 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 89/90) e a denúncia foi recebida (fls. 91/92). Houve citação (fls. 131).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a benesses quanto à pena aplicável, com incidência da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/06, fixação do regime mais benéfico e possibilidade de recorrer em

liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 08), pelo laudo pericial do local (fls. 41/46); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 38/40) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Marcel Rafael de Lima disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e avistou o acusado e ele, ao perceber a presença da guarnição, lançou sacola ao solo. Ele foi submetido a busca pessoal e o depoente retornou ao local onde a sacola havia sido dispensada. No interior dela, localizou três kits, cada um com trinta tubetes de substância aparentando ser cocaína. O acusado disse que estava transportando a droga a uma biqueira. Já havia abordado o acusado em ocasiões anteriores, mas nada ilícito apreendido.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Paulo Eduardo Vedovato.

Em solo policial, o acusado Emerson Pereira Pinto disse que realmente lançou ao solo os tubetes de cocaína. Disse que recebeu os tubetes de um usuário desconhecido, de apelido alemão, de quem não sabe maiores detalhes. Disse que levaria o material a outro rapaz, também desconhecido, ali próximo, mas não teve tempo de fazer a entrega e logo foi preso pelos policiais (fls. 04).

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros e que recebeu R\$ 13,00 para transportar as porções de droga. Informa que deixaria as porções em um local a quatrocentos metros de distância do ponto onde se deu a abordagem.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como as porções apreendidas estavam embaladas, características típicas do tráfico em larga escala.

Anote-se, além disso, que o próprio acusado confessou que recebeu R\$ 13,00 para fazer o transporte da droga e que as porções seriam entregues a 400 metros de distância do local onde se deu a abordagem.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na

medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime a ele. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, anotando-se que o laudo pericial de fls. 38/40 atesta que a massa líquida da substância apreendida era de pouco mais de 15 gramas, o que não justifica a exasperação.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena-base (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 41/45) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimento de ensino, instituição de atendimento a pessoas com deficiência e praças públicas, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta outro processo em curso, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (fls. 19).

A esse respeito: 2. Certo é que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possuem o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Essa, aliás, é a essência do princípio da presunção de não culpabilidade. Contudo, não há óbice a que processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possam, à luz das peculiaridades do concreto concreto, ser considerados elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a

atividades criminosas, notadamente quando verificado que as anotações anteriores também são relativas ao crime de tráfico de drogas. (AgRg no AREsp 938.492/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/09/2016).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO

MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME

SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE

NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios

fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do

tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a

atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas

apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como

constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos

aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial

de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo

revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é

incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena

aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em

virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição

do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o

qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela,

conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao

paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o

pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois

não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo

regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do

eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de

votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei

n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a

garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição

Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial

fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a

eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código

Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá

observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na

Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza

da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese,

verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o

regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico

de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real

necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao

teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da

Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de

reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 – SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Emerson Pereira Pinto à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria, bem como porque figura como réu em outra ação penal, em que supostamente houve emprego de violência, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois o acusado confirmou que recebeu o dinheiro para realizar o transporte da droga.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA